Prüfung Assessmentjahr – Sommer 2024

Teil Prof. Schindler

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Benjamin Schindler (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. Benjamin Schindler

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst **4 Aufgaben auf 12 Seiten** (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

1. Aufgabe	28 Punkte
2. Aufgabe	30 Punkte
3. Aufgabe	15 Punkte
4. Aufgabe	17 Punkte
Total	**90 Punkte**

Schreiben Sie direkt auf die Antwortblätter; sollten Sie Zusatzblätter benötigen, verwenden Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt. Begründen Sie jede Antwort und nennen Sie die einschlägigen Rechtsnormen!

Aufgabe 1 — 28 Punkte

Am 13. Februar 2022 haben Volk und Stände die eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» angenommen. Ziel der Initiative war es, Tabakwerbung überall dort zu verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können, zum Beispiel in der Presse, auf Plakaten, im Internet, im Kino, in Kiosken oder an Veranstaltungen. Erlaubt wäre weiterhin Werbung, die sich nur an Erwachsene richtet oder sich an Orten befindet, zu denen Minderjährige keinen Zugang haben.

Mit der Annahme der Volksinitiative wurde Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV um folgenden Zusatz ergänzt: «er verbietet namentlich jede Art von Werbung für Tabakprodukte, die Kinder und Jugendliche erreicht».

Frage 1: [11 Punkte]

Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen. Legen Sie anschliessend dar, ob Art. 118 Abs. 1 und 2 BV Bundeskompetenzen begründen und kategorisieren sie nach Umfang, Wirkung und Staatsfunktion.

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund nur zuständig, soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Dies entspricht auch dem Gedanken der Subsidiarität, der in Art 5*a* BV festgehalten ist; er ist aber nur eine «politische Klugheitsregel» und vermag die realen Kompetenzen nicht zu beeinflussen (**1 Bonuspunkt**).

Art. 118 Abs. 1 BV begründet für sich allein keine Bundeskompetenz (**0.5 Punkt**), deutet aber auf eine fragmentarische Bundeskompetenz hin, die in den darauffolgenden Absätzen konkretisiert wird (**0.5 Punkt**). Darauf deuten der Wortlaut («Der Bund trifft im Rahmen seiner Zuständigkeiten…») (**1 Punkt)** sowie die Stellung innerhalb der Bundesverfassung (3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden) hin (**1 Punkt**).

Für die in Art. 118 Abs. 2 BV genannten Teilbereiche verfügt der Bund über eine umfassende Bundeskompetenz (**1 Punkt**). In diesem Ausmass ist die Wirkung der Bundeskompetenz nachträglich derogatorisch (**1 Punkt**), da es dem Sinn des Gesundheitsschutzes widersprechen würde, wenn die Kantone nicht tätig werden könnten, würde der Bund seine Kompetenz nicht ausüben (**1 Punkt**). Art. 118 BV äussert sich nicht explizit zur Staatsfunktion, weshalb der Bund i.S.v. Art. 46 BV (**1 Punkt**) die Zuständigkeit zum Vollzug selbst festlegen kann (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 6, Rz. 4 ff., 18 ff.; Fragenkatalog 3, Frage 10 und 13)

Fortsetzung des Sachverhalts:

Das Parlament tut sich schwer, die von Volk und Ständen angenommene Tabakwerbeverbotsinitiative auf Gesetzesstufe umzusetzen. Eine Gesetzesvorlage, die ein umfassendes Werbeverbot für Tabakprodukte mit gewissen Ausnahmeregelungen vorsieht, ist am 29. Februar 2024 im Nationalrat am Widerstand der SVP, der SP und der Grünen gescheitert. Der SVP ging der vorgeschlagene Gesetzesentwurf zu weit: Mit Verweis auf die freie Marktwirtschaft dürfe es nicht sein, dass Tabakwerbung künftig auch in Publikationen wie der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) verboten sein sollen, die ja – gemäss Auffassung des Fraktionssprechers – kaum von Minderjährigen gelesen werden. Der SP und den Grünen hingegen ging der Gesetzesentwurf nicht weit genug: Die vorgesehenen Ausnahmeregelungen für die Tabakfirmen wollen sie nicht hinnehmen, da dies eine Missachtung des Volkswillens darstellen würde. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen müsse an erster Stelle stehen.

In der NZZ wird die vorerst gescheiterte Umsetzung des Tabakwerbeverbots wie folgt kommentiert: «In der Sache sind die Unstimmigkeiten auf den ersten Blick erstaunlich, weil der Kern des neuen Verfassungsartikels unmissverständlich klar erscheint: Der Bund ‹verbietet namentlich jede Art von Werbung für Tabakprodukte, die Kinder und Jugendliche erreicht›. Der zweite Blick hingegen offenbart, wie unterschiedlich sich dieser Auftrag – je nach Interessen, die jemand vertritt – auslegen lässt.»

(NZZ vom 1. März 2024, S. 9)

Frage 2: [6 Punkte]

Weshalb muss Recht ausgelegt werden? Nennen Sie zwei Gründe.

Ein Grund ist, dass Rechtsnormen in Sprache gefasst sind (**1 Punkt**). Die Sprache als Ausdrucksund Kommunikationsmittel ist unvollkommen. Personen fassen Begriffe unterschiedlich auf, und Begriffe können die Lebensrealität nur unvollständig abbilden (**1 Punkt**). Deswegen muss bei jedem Text die «wahre» Bedeutung, d.h. der konkrete Normsinn, eruiert werden (**1 Punkt**).

Der andere Grund ist, dass das Recht aus im Voraus abgefassten generell-abstrakten Normen besteht (**1 Punkt**). Eine generell-abstrakte Rechtsnorm ist so formuliert, dass sie eine ganze Kategorie von gleichgelagerten Fällen erfasst (**1 Punkt**). Die Anwendung erfolgt jedoch im Einzelfall, es muss also ein Fall aus der Realität in die abstrakte Schematik der Rechtsordnung «eingepasst» werden (**1 Punkte**).

(Vgl. Fragenkatalog 1, Frage 5)

Frage 3: [7 Punkte]

Betrachten Sie die Argumente der SVP sowie diejenigen der SP und Grünen. Finden Sie je ein Argument, dass die Position der SVP respektive diejenige der SP und der Grünen verfassungsrechtlich untermauert. Legen Sie dazu Art. 118 Abs. 2 Bst. b Satz 2 BV systematisch aus. Beschreiben Sie zudem kurz, wie sie bei der systematischen Auslegung im Allgemeinen vorgehen.

Das systematische Auslegungselement setzt die Norm in Beziehung zu anderen Normen in Bezug auf ihre Stellung innerhalb der Verfassung selbst und der Rechtsordnung als Ganzes (**1 Punkt**).

Die Position der SVP lässt sich mit der Wirtschaftsfreiheit in Art. 27 BV begründen (**1 Punkt**). Die Wirtschaftsfreiheit schützt die freie Ausübung einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. Ein Werbeverbot beschränkt die Mittel, mit denen Tabakhersteller am Markt teilnehmen können (**1 Punkt**). Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV ist deshalb so umzusetzen, dass der Eingriff in die freie Marktwirtschaft möglichst gering bleibt (**1 Punkt**).

Die Position der SP respektive der Grünen lässt sich mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in Art. 11 BV begründen (**1 Punkt**). Kinder brauchen besonderen Schutz, um ihre Gesundheitskompetenz entwickeln zu können, bevor sie mit Tabakwerbung in Kontakt kommen (**1 Punkt**). Deshalb ist Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV möglichst weit auszulegen, sodass das Tabakwerbeverbot in möglichst alle Lebensbereiche ausstrahlt, mit denen Kinder und Jugendliche in Kontakt treten könnten (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 2, Rz. 43 ff.)

Frage 4: [4 Punkte]

Weshalb kann es innerhalb der Verfassung zu Widersprüchen kommen? Welche Besonderheit ergibt sich dadurch für die systematische Auslegung? Sehen Sie darin Gefahren?

Die Bevölkerung in der Schweiz kann die Verfassung über die Volksinitiative jederzeit ändern. Dieses direktdemokratische Mitwirkungsinstrument kann dazu führen, dass aus einem aktuellen Anlass eine einzelne Bestimmung in die Verfassung eingefügt wird, die anderen Verfassungsnormen widerspricht (**1 Punkt**). Im Rahmen der systematischen Auslegung ist deshalb darauf zu achten, dass die Verfassungsbestimmungen in praktische Konkordanz gebracht werden (**1 Punkt**), dass also keine Widersprüche innerhalb der Verfassung auftreten (Harmonisierung) (**1 Punkt**). Es besteht hier aber die Gefahr, dass bewusst in Kauf genommene Konflikte entgegen dem Normsinn «wegharmonisiert» werden und eine wertende Normenhierarchie geschaffen wird (**1 Punkt**).

(Vgl. Fragenkatalog 1, Frage 6)

Aufgabe 2 — 30 Punkte

Moutier ist eine französischsprachige Einwohnergemeinde im Kanton Bern. Bei der Schaffung des ebenfalls französischsprachigen Kantons Jura im Jahr 1978 hatte sich Moutier entschieden, weiterhin zum Kanton Bern gehören zu wollen. In den folgenden Jahrzehnten verlangten Separatisten immer wieder die Abspaltung vom Kanton Bern. Dies wurde auch mehrfach zur Abstimmung gebracht, bis zuletzt aber ohne Erfolg. Erst in der Volksabstimmung vom 28. März 2021 sprachen sich 54.85% des Stimmvolks der Gemeinde Moutier für einen Wechsel zum Kanton Jura aus.

Frage 1: [7 Punkte]

Lässt die Bundesverfassung den Kantonswechsel einer Gemeinde überhaupt zu? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Beziehen Sie Ihre Antwort auf den Kantonswechsel der Gemeinde Moutier!

Die Gebietsgarantie nach Art. 53 Abs. 1 BV bedeutet nicht, dass Änderungen im Gebiet der Kantone a priori ausgeschlossen sind, sondern dass sie in einem geordneten (verfassungsmässigen) Verfahren erfolgen müssen, das die demokratische und föderalistische Mitsprache garantiert (**1 Punkt**). Die Verfahrensvorschriften für eine Gebietsveränderung (**1 Punkt**) zwischen Kantonen sind in Art. 53 Abs. 3 BV enthalten (**1 Punkt**). Es müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Zustimmung der Bevölkerung im betroffenen Gebiet (**0.5 Punkte**), also der Bevölkerung von Moutier (**0.5 Punkte**)
- Zustimmung der betroffenen Kantone (**0.5 Punkte**), also der Kantone Bern und Jura (**0.5 Punkte**)
- Genehmigung der Bundesversammlung (**0.5 Punkte**) in der Form eines Bundesbeschlusses (**0.5 Punkt**), der dem fakultativen Referendum untersteht (vgl. Art. 141 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 163 Abs. 2 BV *e contrario*) (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 6, Rz. 61 ff.; Fragenkatalog 3, Frage 20)

Fortsetzung des Sachverhalts:

Seit dem Volksentscheid der Gemeinde Moutier verhandeln die Kantone Jura und Bern über die Details des Kantonswechsels von Moutier. Am 23. November 2023 haben die Regierungen der Kantone Bern und Jura ein Konkordat unterzeichnet, das die wichtigsten Punkte des Kantonswechsels regelt, beispielsweise die Kontinuität in den Bereichen Verwaltung, Steuern, Schule, Justiz und Spitalwesen.

Frage 2: [6 Punkte]

Dürfen Kantone untereinander Verträge schliessen und falls ja, unter welchen Voraussetzungen? Wo wären diese innerhalb der Normenhierarchie anzusiedeln?

Kantone dürfen gestützt auf Art. 48 Abs. 1 BV miteinander Verträge abschliessen (**1 Punkt**). Art. 48 Abs. 3 BV hält jedoch fest, dass Verträge der Kanone dem Recht und den Interessen des Bundes sowie den Rechten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen dürfen (**1 Punkt**).

Nach dem Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1 BV) (**1 Punkt**) steht interkantonales Recht in der Normenhierarchie unterhalb des Bundesrecht (**1 Punkt**). Nach Art. 48 Abs. 5 BV sind die Kantone verpflichtet, interkantonales Recht zu beachten (**1 Punkt**). Daraus wird abgeleitet, dass interkantonales Recht im Rang über dem kantonalen Recht steht (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 3, Rz. 46 sowie § 6, Rz. 53 ff.; Fragenkatalog 2, Frage 3 b)

*Hinweis: Gehen Sie für die folgende Aufgaben davon aus, dass die Abstimmung über den Kantonswechsel von Moutier **erfolglos** war und die Gemeinde Moutier weiterhin Teil des Kantons Bern ist.*

Der nachfolgende Sachverhalt ist frei erfunden:

Der Berner Jura ist ein französischsprachiger Verwaltungskreis im Kanton Bern, zu dem auch Moutier gehört. Im Nachgang zur knapp verlorenen Abstimmung zum Kantonswechsel der Gemeinde Moutier kommt im gesamten Berner Jura eine neue Forderung auf: Der Berner Jura soll ein eigener Kanton mit dem Namen «Grand Chasseral» werden.

Frage 3: [10 Punkte]

Ist dieses Vorhaben verfassungsrechtlich zulässig und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Beziehen Sie Ihre Antwort auf die Schaffung des neuen Kantons «Grand Chasseral».

Grundsätzlich schützt der Bund den Bestand der Kantone (sog. Bestandesgarantie nach Art. 53 Abs. 1 BV) (**1 Punkt**). Die Schaffung eines neuen Kantons ist jedoch mit einer Änderung im Bestand der Kantone (**1 Punkt**) nach Art. 53 Abs. 2 BV (**1 Punkt**) möglich.

Dafür erforderlich sind:

- die Zustimmung der betroffenen Bevölkerung (**0.5 Punkt**), d.h. der Stimmberechtigten der Gemeinden des Berner Juras (**0.5 Punkt**);
- die Zustimmung der betroffenen Kantone (**0.5 Punkt**), d.h. des Kantons Bern (**0.5 Punkt**); sowie
- die Zustimmung von Volk und Ständen (**1 Punkt**).

Mit der Bestandesänderung einher gehen verschiedene Verfassungsänderungen (**1 Punkt**). So muss Art. 1 BV (**1 Punkt**) den neuen Kanton «Grand Chasseral» in der Auflistung der Kantone aufnehmen (**0.5 Punkt**) und Art. 150 Abs. 1 BV (**1 Punkt**) benötigt eine Anpassung in der Zusammensetzung des Ständerates, da es neu 48 anstatt

46 Abgeordnete gibt (**0.5 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 6, Rz. 61 ff.; Fragenkatalog 3, Frage 19)

Der nachfolgende Sachverhalt ist frei erfunden:

Gehen Sie davon aus, dass der Berner Jura in allen Abstimmungen die erforderlichen Mehrheiten erreichen konnte und nun nicht mehr zum Kanton Bern gehört, sondern zum Kanton «Grand Chasseral» geworden ist. In diesem Zusammenhang muss sich der junge Kanton eine neue Kantonsverfassung geben. In der vom Parlament des Kantons «Grand Chasseral» beschlossenen Kantonsverfassung findet sich die folgende Bestimmung:

Art. 78 Revision der Kantonsverfassung

[1] Die Kantonsverfassung kann nach Ablauf von 2 Jahren nach ihrer Annahme jederzeit vom Volk revidiert werden.
[2] [...]

Frage 4: [7 Punkte]

Welche Anforderungen stellt die Bundesverfassung an Kantonsverfassungen? Wer stellt sicher, dass die Kantonsverfassungen diese Anforderungen auch erfüllen? Würde Art. 78 der Kantonsverfassung von «Grand Chasseral» diesen Anforderungen genügen?

Die Bundesverfassung fordert nach Art. 51 Abs. 1 BV demokratische Kantonsverfassungen (**1 Punkt**), die minimale politische Rechte gewährleisten (**1 Punkt**).

Der Bund gewährleistet Kantonsverfassungen (**1 Punkt**), wenn sie dem Bundesrecht nicht widersprechen (Art. 51 Abs. 2 BV) (**1 Punkt**). Dafür zuständig ist nach Art. 172 Abs. 2 BV die Bundesversammlung (**1 Punkt**).

Art. 78 Abs. 1 der Kantonsverfassung von «Grand Chasseral» sieht eine 2-jährige Karenzfrist für Verfassungsrevisionen vor (**1 Punkt**). Diese Bestimmung genügt den Anforderungen nicht, da dadurch die jederzeitige Abänderbarkeit nicht gegeben wäre (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 6, Rz. 59; Fragenkatalog 3, Frage 22 und Frage 23 a)

Aufgabe 3 — 15 Punkte

Die Vereinigung «Türkische Föderation Schweiz» plante für Samstag, 18. März 2017, ab 18:00 Uhr eine Gedenkveranstaltung zur Schlacht von Gallipoli in einem Saal in Reinach/BL. Die Polizei Basel-Landschaft erfuhr wenige Tage vor der Veranstaltung jedoch, dass aus Kreisen der Antifa zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen wurde. Nach Angaben der Polizei bestehe angesichts der politischen Spannung zwischen den beiden Gruppierungen ein hohes Potenzial für gewaltsame Auseinandersetzungen, wobei auch mit dem Einsatz von Waffen oder Schlaginstrumenten zu rechnen sei. Da am selben Abend überdies ein Fussballspiel zwischen dem FC Basel und dem Grasshopper Club Zürich stattfindet, das als Hochrisikospiel eingestuft wird, verfügt die Polizei so kurzfristig nicht über genügend personelle Ressourcen, um die Veranstaltung in Reinach ebenfalls adäquat zu schützen.

Die Vereinigung «Türkische Föderation Schweiz» gelangt nach Durchlaufen des kantonalen Instanzenzuges an das Bundesgericht und kritisiert dabei unter anderem, dass das gegen ihre Veranstaltung ausgesprochene Verbot nicht über eine ausreichende gesetzliche Grundlage verfüge.

Frage 1: [15 Punkte]

Gehen Sie davon aus, dass keine geeignete gesetzliche Grundlage besteht. Wie muss die Polizei Basel-Landschaft argumentieren, um der Kritik der fehlenden gesetzlichen Grundlage zu entgegnen?

Die Polizei dürfte ohne gesetzliche Grundlage handeln, wenn die Voraussetzungen der polizeilichen Generalklausel (**1 Punkt**) erfüllt sind:

Es muss ein *fundamentales Rechtsgut* betroffen sein. Zu den fundamentalen Rechtsgütern gehören Rechtsgüter, die für Private (Leib, Leben, Gesundheit) oder den Staat (innerer/äusserer Frieden, äussere Unabhängigkeit) von existenzieller Bedeutung sind (**1 Punkt**). Vorliegend sind die öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie Leib und Leben der Veranstaltungsteilnehmenden betroffen (**1 Punkt**)

Eine *schwere Gefahr* für das Schutzgut (sachliche Dringlichkeit) liegt vor, wenn dem Schutzgut eine schwere Beeinträchtigung droht (**1 Punkt**). Da ein hohes Potenzial für gewaltsame Auseinandersetzungen besteht, ist diese zu bejahen (**1 Punkt**).

Zeitliche Dringlichkeit ist gegeben, wenn die konkrete Gefahrensituation kein Zuwarten erlaubt, d.h. keine gesetzliche Grundlage geschaffen werden kann (**1 Punkt**). Die Gedenkveranstaltung findet in wenigen Tagen statt, was für zeitliche Dringlichkeit spricht (**1 Punkt**).

Geeignete gesetzliche Mittel fehlen, wenn das geltende Recht kein Mittel vorsieht, um der Gefahr wirksam zu begegnen (**1 Punkt**). Dies ist vorliegend gemäss Sachverhalt erfüllt (**1 Punkt**).

Eine *atypische Gefährdungslage* liegt vor, wenn sie vom Gesetzgeber nicht

vorhergesehen werden konnte, wenn also beim Fehlen einer Regelung von einem Versehen und nicht von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzgebers auszugehen ist (**1 Punkt**). Der Umgang mit Veranstaltungen mit Konfliktpotential ist eine typische Aufgabe der Polizei, weshalb nicht von einer unvorhersehbaren, atypischen Gefährdungslage ausgegangen werden kann (**1 Punkt**). Allerdings ist umstritten, ob diese Voraussetzung (Unvorhersehbarkeit) noch gilt (**1 Punkt**). Die neuere bundesgerichtliche Rechtsprechung scheint zumindest dann darauf zu verzichten, wenn eine besonders schwere Gefahr für ein Rechtsgut droht (**1 Punkt**). Da vorliegend eine schwere Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie Leib und Leben der Veranstaltungsteilnehmenden droht, kann auf die atypische Gefährdungslage verzichtet werden (**1 Punkt**).

Somit kann die Polizei ihr Handeln auf die polizeiliche Generalklausel stützen und eine fehlende gesetzliche Grundlage ersetzen (**1 Punkt**).

(Sachverhalt und Lösung basierend auf BGE 147 I 161; vgl. Reader, § 4, Rz. 19; Fragenkatalog 2, Frage 12 und 13 d)

Aufgabe 4 — 17 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Harry lernt gerne in der Bibliothek der Universität St. Gallen für seine Prüfungen. Leider trifft er aufgrund Verspätung seiner ÖV-Verbindung regelmässig erst um etwa 08:20 Uhr in der Bibliothek ein. Mehrmals musste er dann frustriert feststellen, dass es keine freien Lernplätze mehr gibt. Ihm ist dabei aufgefallen, dass allzu oft andere Studierende mehrere Plätze für ihre erst später eintreffenden Freunde reservieren. Als er das nächste Mal vergeblich einen Platz sucht, ist dies der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er beginnt in der Bibliothek lautstark einen Streit mit einem Kommilitonen, der offensichtlich mehrere Plätze reserviert hat. In der Folge wird Harry vom Sicherheitsdienst aus der Bibliothek eskortiert und erhält von der Disziplinarkommission der Universität ein Bibliotheksverbot für den Rest der Lernphase. Er empfindet dies als äusserst ungerecht und will sich rechtlich dagegen wehren.

Frage 1: [3 Punkte]

Aus einer Bundesstaatsrechtsvorlesung im Assessment weiss Harry noch, dass er eigentlich ein verfassungsmässiges Recht auf eine faire Behandlung hat. Ist diese Garantie in seinem Fall anwendbar?

Die Verfahrensgarantien gemäss Art. 29 BV (**0.5 Punkte**) – und damit insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren – sind in jedem Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen anwendbar, die auf den Erlass eines verbindlichen, individuell-konkreten Entscheids ausgerichtet sind (**0.5 Punkte**). Im vorliegenden Verfahren entscheidet die Disziplinarkommission der Universität St. Gallen als Verwaltungsinstanz verbindlich über die individuell-konkrete Frage (**0.5 Punkte**), ob Harry für den Rest der Lernphase ein Bibliotheksverbot erhält, womit das Recht auf ein faires Verfahren anwendbar ist (**0.5 Punkte**). Harry ist als natürliche Person zudem Träger dieser Verfahrensgarantien (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 4, Rz. 46; Fragenkatalog 2, Frage 19)

Frage 2: [5 Punkte]

Harry legt Rekurs gegen das Bibliotheksverbot bei der universitätsinternen Rekursstelle der Universität St. Gallen ein. Da ihm die Sache sehr wichtig ist, nimmt er sich sehr viel Zeit und begründet seinen Rekurs gründlich und ausführlich. Die Rekursstelle lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und teilt ihm schriftlich mit, dass sie «die Argumente nicht interessieren» und sie diese nicht berücksichtigen wird. Nach kürzester Zeit lehnt die Rekursstelle den Rekurs daraufhin ab. Auf Nachfrage von Harry, weshalb so entschieden wurde, verweigert ihm die Rekursstelle die Auskunft.

Welche Verfahrensgrundrechte wurden vorliegend verletzt? Nennen Sie zwei und begründen Sie Ihre Antwort.

Vorliegend wurde das rechtliche Gehör (**0.5 Punkte**) gemäss Art. 29 Abs. 2 BV (**0.5 Punkte**) verletzt. Einer der Teilgehalte dieses Anspruchs ist nach bundesgerichtlicher Praxis das Recht auf Prüfung der Argumente (**1 Punkt**). Indem die Rekursstelle die Argumente von Harry nicht berücksichtigte (**0.5 Punkte**), hat sie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt (**0.5 Punkte**). Ein weiterer Teilgehalt ist das Recht auf Begründung des Entscheids (**1 Punkt**). Indem die Rekursstelle Harry keine Antwort darauf gibt, weshalb sie so entschieden hat (**0.5 Punkte**), verletzt sie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör erneut (**0.5 Punkte**).

(Vgl. Reader, § 4, Rz. 48; Fragenkatalog 2, Frage 21)

Frage 3: [3 Punkte]

Harry fühlt sich nun auch durch die universitätsinterne Rekursstelle ungerecht behandelt. Er ist überzeugt, dass der Entscheid anders ausgefallen wäre, wenn das Verfahren vor der Rekursstelle öffentlich gewesen wäre. Hat Harry gestützt auf die Bundesverfassung einen Anspruch, dass das Verfahren vor der universitätsinternen Rekursstelle öffentlich ist?

Nach Art. 30 Abs. 3 BV (**0.5 Punkte**) sind Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung grundsätzlich öffentlich (**0.5 Punkte**). Art. 30 Abs. 3 BV ist allerdings nur auf gerichtliche Verfahren und nicht auf Verwaltungsverfahren anwendbar **(1 Punkt**). Das Verfahren vor der Rekursstelle ist universitätsintern und damit nicht gerichtlich (**0.5 Punkte**), weshalb Harry keinen Anspruch auf ein öffentliches Verfahren vor der universitätsinternen Rekursstelle hat (**0.5 Punkte**).

(Vgl. Reader, § 4, Rz. 52; Fragenkatalog 2, Frage 22 e)

Frage 4: [4 Punkte]

Im Nachhinein stellt sich heraus, dass Lucius als Mitglied der Rekursstelle am Entscheid der Rekursstelle beteiligt war. Lucius ist der Vater des Kommilitonen, mit dem Harry in der Bibliothek seinen lautstarken Streit geführt hat. Sehen Sie ein Problem darin, dass Lucius am Entscheid der Rekursstelle mitgewirkt hat?

Art. 29 Abs. 1 BV (**0.5 Punkte**) verlangt, dass am Entscheid nur unbefangene und unparteiliche Personen mitwirken (**0.5 Punkte**). Bereits der Anschein der Befangenheit soll ausgeschlossen werden (**0.5 Punkte**). Allerdings muss die Befürchtung der Befangenheit eine gewisse Intensität erreichen sowie objektivierbar sein, also nicht rein subjektiv bestehen (**0.5 Punkte**). Da Harry mit dem Sohn von Lucius einen Streit in der Bibliothek begonnen hat, könnte sich eine Feindschaft zwischen den beiden gebildet haben, die auch die Wahrnehmung von Lucius beeinträchtigen könnte (**1 Punkt**). Lucius scheint daher aus objektiven Gesichtspunkten befangen zu sein (**0.5 Punkte**) und muss demnach in den Ausstand treten (**0.5 Punkte**).

Hinweis: Abweichende Lösung bei guter Argumentation ebenfalls möglich.

(Vgl. Reader, § 4, Rz. 46)

Frage 5: [2 Punkte]

Harry ist mit dem Entscheid nicht zufrieden und will rechtlich gegen ihn vorgehen. Hat er einen verfassungsmässigen Anspruch auf eine Beurteilung durch ein Gericht?

Hinweis: Sie brauchen hier nicht zu subsumieren!

Ja (**0.5 Punkte**), gemäss Art. 29*a* BV (**0.5 Punkte**) hat jede Person bei Rechtsstreitigkeiten den Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde (**1 Punkt**).

(Vgl. Reader, § 4, Rz. 51; Fragenkatalog 2, Fragen 20 und 22 c)

Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schmid

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

Prüfung Assessmentjahr – Frühjahrssemester 2024

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): | Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**
2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

Verantwortlich: **Prof. Dr. Benjamin Schindler**

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst 4 Aufgaben auf 18 Seiten (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	35 Punkte
Aufgabe 2	10 Punkte
Aufgabe 3	15 Punkte
Aufgabe 4	30 Punkte
Total	**90 Punkte**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie **ganze Sätze** und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

Aufgabe 1: Bestätigungswahl des Bundesrates (35 Punkte)

Das Initiativkomitee der eidgenössischen Volksinitiative «Bestätigung der Bundesrätinnen und Bundesräte durch Volk und Stände» will, dass die Mitglieder des Bundesrates regelmässig durch Volk und Stände bestätigt werden müssen.

Die vom Initiativkomitee lancierte Volksinitiative hat folgenden Wortlaut:

> Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
>
> **Art. 145** *Sachüberschrift und Abs. 2–4*
>
> Amtsdauer und Bestätigungswahl
>
> [2] Die Mitglieder des Bundesrates müssen alle zwei Jahre in einer Bestätigungswahl durch Volk und Stände im Amt bestätigt werden. Eine Bestätigung erfolgt durch das Volks- und Ständemehr.
>
> [3] Die Bestätigungswahl findet im September des zweiten Jahres nach der Bundesratswahl durch die Bundesversammlung und im September des zweiten Jahres nach der letzten Bestätigungswahl statt.
>
> [4] Für Mitglieder des Bundesrates, die das Volks- und Ständemehr nicht erreichen, endet die Amtszeit mit dem Tag der Wahl ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger. Die Bundesversammlung wählt die Nachfolgerinnen und Nachfolger bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres, in dem die Bestätigungswahl stattgefunden hat.
>
> (…)

Hinweis: Die bisherige Regelung von Art. 145 BV soll erhalten bleiben und als Abs. 1 in die neue Bestimmung eingefügt werden.

Frage 1)

Aus wie vielen Personen muss ein Initiativkomitee mindestens bestehen? Wie viele Personen dürfen einem Initiativkomitee höchstens angehören? (2 Punkte)

Das Initiativkomitee besteht aus mindestens 7 und höchstens 27 Stimmberechtigten (Art. 68 Abs. 1 Bst. e BPR).

GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich/St.Gallen 2021, § 23 N. 89

Frage 2)

Das Initiativkomitee hat ab Veröffentlichung der Volksinitiative im Bundesblatt 18 Monate Zeit, um die nötigen 100'000 Unterschriften von Stimmberechtigten zu sammeln. Vor Einreichung der gesammelten Unterschriften müssen diese von den kantonalen Amtsstellen bescheinigt werden.

a) Erklären Sie, was unter der sogenannten Stimmrechtsbescheinigung zu verstehen ist. (2 Punkte)

Die kantonalen Amtsstellen haben zu bescheinigen, dass die Unterzeichnenden in der auf der Unterschriftenliste bezeichneten Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind (Art. 62 Abs. 2 i.V.m. Art. 70 BPR).

Vorlesung 2. Teil (I) Folie 25

b) Bei welcher Bundesbehörde sind die gesammelten und von den kantonalen Amtsstellen bescheinigten Unterschriften schliesslich einzureichen? (2 Punkte)

Die bescheinigten Unterschriften sind bei der Bundeskanzlei einzureichen (Art. 71 Abs. 1 BPR).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 89
Vorlesung 2. Teil (I) Folie 25

Frage 3)

Die vorn abgedruckte Volksinitiative möchte unter anderem auf die Amtsdauer der Mitglieder des Bundesrates einwirken.

a) Wer wählt nach geltendem Recht die Mitglieder des Bundesrates und wie ist deren Amtsdauer heute geregelt? (4 Punkte)

Die Wahl der Mitglieder des Bundesrates obliegt der Bundesversammlung, die zu diesem Zweck als Vereinigte Bundesversammlung zusammentritt (Art. 157 Abs. 1 Bst. a BV). Die Mitglieder des Bundesrates werden einzeln auf eine feste Amtsdauer von vier Jahren gewählt (Art. 175 Abs. 3 BV).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 19 N. 11 ff.
Vorlesung 2. Teil (V) Folien 7, 9

b) Kann der Gesamtbundesrat nach geltendem Recht vorzeitig abberufen werden? Besteht ein vorzeitiges Abberufungsrecht nach geltendem Recht bezüglich der einzelnen Mitglieder des Bundesrates? (4 Punkte)

Die Bundesversammlung hat keine Möglichkeit, die Regierung als Ganzes durch ein Misstrauensvotum zu stürzen, wie dies in parlamentarischen Regierungssystemen möglich ist. Auch eine vorzeitige Abberufung einzelner Regierungsmitglieder ist nicht möglich. Eine Verkürzung der Amtsdauer kann – theoretisch – über den Umweg von Art. 193 BV erfolgen, da nach der Zustimmung des Volkes zur Durchführung einer Totalrevision beide Räte neu gewählt werden (Art. 193 Abs. 3 BV) und die Mitglieder des Bundesrates nach jeder Gesamterneuerung des Nationalrates neu gewählt werden (Art. 175 Abs. 2 BV).

In der Praxis ist es auch schon vorgekommen, dass politische Parteien versucht haben, unliebsame Mitglieder des Bundesrates politisch unter Druck zu setzen, um sie zu einem mehr oder weniger freiwilligen Rücktritt zu bewegen.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 19 N. 14 f.
Vorlesung 2. Teil (I) Folie 21

Frage 4)

Magdalena, die letztes Jahr mit Bestnoten das Assessmentjahr der Universität St.Gallen bestand, steht der eidgenössischen Volksinitiative «Bestätigung der Bundesrätinnen und Bundesräte durch Volk und Stände» sehr kritisch gegenüber. Ihrer Ansicht nach steht die vom Initiativkomitee geforderte Bestätigungswahl in einem Spannungsverhältnis zum Kollegialprinzip.

a) Erklären Sie zunächst, was man unter dem Kollegialprinzip versteht, und legen Sie anschliessend dar, inwiefern Magdalenas Kritikpunkt zutrifft. (8 Punkte)

Das Kollegialprinzip ist ein Verfassungsprinzip, das in Art. 177 BV ausdrücklich festgehalten wird. Danach besteht der Bundesrat aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern. Er übt die ihm übertragenen (Regierungs-)Funktionen als Kollegium, d.h. als Einheit, aus (Art. 177 Abs. 1 BV). Niemand – weder ein einzelnes Mitglied noch ein Ausschuss – kann im Namen des Bundesrates Beschluss über ein Geschäft fassen, das in die Zuständigkeit des Gesamtbundesrates fällt. Zu den anerkannten Gehalten des Kollegialprinzips gehört aber, dass die Regierungsmitglieder die getroffenen Kollegiumsentscheide sowohl nach aussen (Bundesversammlung, Öffentlichkeit) als auch nach innen (Departement) zu vertreten haben, und zwar auch dann, wenn der Kollegiumsentscheid nicht den eigenen Überzeugungen entspricht.

Durch die Annahme der Volksinitiative würde sich die Möglichkeit eröffnen, einzelne Mitglieder des Bundesrates alle zwei Jahre vorzeitig abzuberufen.

Ein solches System könnte sich insofern nachteilig auf das Kollegialprinzip auswirken, als die ständige Gefahr, von Volk und Ständen nicht bestätigt zu werden, zu einer Politik führen könnte, die mehr auf individuelle Profilierung als auf kollegiale Staatsführung ausgerichtet ist. Dies würde die Qualität und Stabilität der politischen Entscheidungsfindung beeinträchtigen.

Eine solche Bestätigungswahl könnte dazu führen, dass die Mitglieder des Bundesrates stärker als heute als parteipolitische Akteurinnen und Akteure wahrgenommen würden. Ihre Rolle als Regierungsmitglieder und Departementsvorsteherinnen bzw. Departementsvorsteher würde sich mit ihrer neuen Rolle als Aushängeschilder und Wahllokomotiven für ihre Partei und als Kandidatinnen und Kandidaten auf ungute Weise vermischen. Im Interesse ihrer Wiederwahl müssten sie noch stärker als heute mit den Medien kooperieren.

Da die Mitglieder des Bundesrates gemeinsam die Verantwortung für alle wichtigen politischen Fragen tragen, wäre es mit dem Kollegialprinzip kaum vereinbar, wenn einzelne Mitglieder des Bundesrates vorzeitig aus dem Kollegium abberufen werden könnten.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 19 N. 57 ff.
Vorlesung 2. Teil (V) Folie 17

b) Magdalena versucht, neben dem Spannungsverhältnis zum Kollegialprinzip weitere inhaltliche Argumente zu finden, die gegen die vorn abgedruckte Volksinitiative sprechen. Helfen Sie Magdalena und nennen Sie ein weiteres inhaltliches Argument, das gegen die vorn abgedruckte Volksinitiative vorgebracht werden könnte. (2 Punkte)

- *Zunächst würde eine Lösung, wie sie das Initiativkomitee vorschlägt, zu einem ständigen Wahlkampf führen, der die Mitglieder des Bundesrates stark belasten würde. Sie müssten sich damit einem zeitraubenden Dauerwahlkampf stellen.*
- *Zudem könnten die finanziellen Anforderungen an die Parteien steigen, da diese voraussichtlich auch (Bestätigungs-)Wahlkämpfe finanzieren müssten. Dies würde die finanzielle Abhängigkeit von ihren Geldgebern erhöhen.*
- *Ausserdem hätten Mitglieder des Bundesrates aus der Deutschschweiz wohl einen Vorteil.*

Anmerkung: Weitere überzeugende Argumente wurden ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Frage 5)

Die vorn abgedruckte Volksinitiative möchte nicht nur das Stimmvolk, sondern auch die Stände in die Bestätigungswahl der Mitglieder des Bundesrates einbinden. Welche Überlegungen könnten hinter dieser Einbindung der Stände stehen? (4 Punkte)

Das Ständemehr (Art. 142 BV) stellt den Einbezug der Kantone an der Beschlussfassung im Bund sicher und dient dem Schutz des Föderalismus. Wäre nur das Volksmehr massgebend, könnten einige bevölkerungsreiche Kantone alle anderen Kantone überstimmen. Bevölkerungsarme Kantone hingegen üben bei der Bestätigungswahl durch das nötige Ständemehr einen erheblichen Einfluss aus, wäre es doch denkbar, dass ein Mitglied des Bundesrates zwar die Mehrheit der Volks-, nicht jedoch der Standesstimmen erreichte. Die föderalistische Legitimation der Mitglieder des Bundesrates würde damit gestärkt.

Vorlesung 2. Teil (I) Folie 26

Frage 6)

In einem Zeitungsinterview antwortete einer der Initianten auf die Frage, was für die eidgenössische Volksinitiative «Bestätigung der Bundesrätinnen und Bundesräte durch Volk und Stände» spreche, wie folgt: «Das Volk ist der Boss.»

Nehmen Sie zu dieser salopp formulierten Aussage aus verfassungsrechtlicher Sicht Stellung! Gehen Sie dabei auch auf diejenigen politischen Rechte ein, welche das Stimmvolk in der Schweiz nach geltendem Verfassungsrecht besitzt. (7 Punkte)

Tatsächlich hält Art. 148 Abs. 1 BV fest, dass die Bundesversammlung «unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen» die oberste Gewalt im Bund ausübt. Somit wird die Stellung der Bundesversammlung als «oberste Gewalt» durch die Bundesverfassung selbst insbesondere im Sinne des Grundsatzes der Volkssouveränität relativiert. Mit der Formulierung von Art. 148 Abs. 1 BV wird einerseits auf die Wahl der Mitglieder der Bundesversammlung (Art. 149 BV) durch die Wahlberechtigten Bezug genommen. Anderseits wird dem Umstand Rechnung getragen, dass mittels der direktdemokratischen Mitwirkungsrechte der Volksinitiative (Art. 138 und 139 BV) und des obligatorischen und des fakultativen Referendums (Art. 140 und Art. 141 BV) die Möglichkeit der direkten Einflussnahme durch Volk und Stände besteht.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 4 f., 15; § 23 N. 86 ff., 111 ff., 146 ff.; § 24 N. 14 ff.
Vorlesung 2. Teil (I) Folien 16 ff.

Aufgabe 2: Parlamentswörterbuch (10 Punkte)

Nennen Sie den gesuchten Begriff und **eine** dazugehörige Rechtsgrundgrundlage in der Bundesverfassung oder einem Bundesgesetz. (keine Begründung erforderlich)

Beispiel
Das _____ schützt die Ratsmitglieder vor verbindlichen Weisungen. Es verbietet jedoch nicht, dass sich die Ratsmitglieder freiwillig an Abreden halten oder dass sie Interessen vertreten. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Instruktionsverbot (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 161 Abs. 1 BV

Frage 1)
Das _____ bezweckt die Beteiligung der Kantone, der politischen Parteien und der interessierten Kreise an der Meinungsbildung und Entscheidfindung des Bundes. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Vernehmlassungsverfahren (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 147 BV; Art. 2 Abs. 1 VlG

Frage 2)
Eine _____ konkretisiert die gesetzlichen Bestimmungen und muss sich an den gesetzlichen Rahmen halten. Insbesondere darf sie keine neuen Vorschriften aufstellen, welche die Rechte der Bürger beschränken oder ihnen neue Pflichten auferlegen. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Vollziehungsverordnung (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 182 Abs. 2 BV

Frage 3)
Die Abgeordneten des Nationalrates werden vom Volk in direkter Wahl nach dem Grundsatz des _____ bestimmt. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Proporzes (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 149 Abs. 2 BV

Frage 4)
Der Begriff _____ bezeichnet das Verbot für Behördenmitglieder, gleichzeitig einer anderen Behörde anzugehören. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Unvereinbarkeit (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 144 Abs. 1 BV

Frage 5)
Das _____ beauftragt den Bundesrat zu prüfen und zu berichten, ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen ist.

Gesuchter Begriff: Postulat (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 118 f. ParlG

Aufgabe 3: Grundrechtstheorie (15 Punkte)

Frage 1)

Welches sind mögliche Rechtsquellen von Grundrechten? Nennen Sie deren drei! (Nennung genügt, keine Begründung nötig) (3 Punkte)

Mögliche Rechtsquellen von Grundrechten sind:

- *die Bundesverfassung;*
- *die Kantonsverfassungen;*
- *die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK);*
- *der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNO-Pakt I);*
- *der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II) sowie*
- *weitere internationale Abkommen.*

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 30 N. 17 ff.
Vorlesung 2. Teil (II) Folie 7

Frage 2)

Neben Grundrechten gibt es auch Grundpflichten. Erklären Sie, was man unter Grundpflichten versteht, und nennen Sie ein Beispiel einer in der Bundesverfassung vorgesehenen Grundpflicht. (3 Punkte)

Als Grundpflichten werden gemeinhin elementare Pflichten der Einzelnen bezeichnet, die für die Existenz des Staates von zentraler Bedeutung sind.

Beispiele: Militär- und Ersatzdienstpflicht (Art. 59 BV); Grundschulobligatorium (Art. 62 Abs. 2 BV)

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 29 N. 6 ff.
Vorlesung 2. Teil (II) Folie 16

Frage 3)

Wodurch unterscheiden sich die sozialen Grundrechte von den Sozialzielen? Nennen Sie zudem ein in der Bundesverfassung vorgesehenes soziales Grundrecht und ein Sozialziel. (4 Punkte)

Bei den sozialen Grundrechten handelt es sich um individuelle Ansprüche auf staatliche Leistungen (z.B. auf eine Sozialwohnung oder auf Sozialversicherungsleistungen), wobei sich ein direkter Anspruch aus der Bundesverfassung ergibt. Ein Beispiel für ein in der Bundesverfassung verankertes soziales Grundrecht ist das in Art. 12 BV vorgesehene Recht auf Hilfe in Notlagen (ebenfalls soziale Grundrechte sind Art. 11, Art. 19 und Art. 29 Abs. 3 BV). Hingegen handelt es sich bei Sozialzielen um keine individuellen und direkten Ansprüche von Privaten auf staatliche Leistungen, sondern vielmehr um Sozialgestaltungsaufträge. Dabei werden sowohl rechtsetzende als auch rechtsanwendende Behörden zur Umsetzung verpflichtet. Ein Beispiel für ein in der Bundesverfassung verankertes Sozialziel stellt Art. 41 BV dar. Dieser legt verschiedene Sozialziele fest, die der Bund und die Kantone verfolgen sollen.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 41 N. 5 ff., 10 f.
Vorlesung 2. Teil (II) Folie 11

Frage 4)

Ist eine (nichtstaatliche) Privatklinik, die Schönheitsoperationen anbietet, unmittelbar an die Grundrechte gebunden? (5 Punkte)

Im Verhältnis unter Privaten gilt grundsätzlich die Privatautonomie; Grundrechte binden nur diejenigen Organe, Behörden und Personen, welche staatliche Aufgaben wahrnehmen. Grundrechte wirken also grundsätzlich nur im Vertikalverhältnis zwischen Trägern staatlicher Aufgaben und Privaten. Eine unmittelbare Wirkung im Horizontalverhältnis, d.h. zwischen Privaten, liegt einzig dann vor, wenn aus der Bundesverfassung unmissverständlich hervorgeht, dass ein Grundrecht auch unter Privaten gelten soll. Eine solche sog. direkte Drittwirkung ist bisher nur für Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV anerkannt; das Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit verpflichtet neben dem Staat auch private Arbeitgebende.
Schönheitsoperationen gehören nicht zu den staatlichen Aufgaben, weshalb die Privatklinik darüber hinaus nicht unmittelbar an die Grundrechte gebunden ist.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 30 N. 76
Vorlesung 2. Teil (II) Folie 14

Aufgabe 4: Verkaufsverbot für Alkohol (30 Punkte)

In einem Zeitungsartikel vom 2. Februar 2023 war Folgendes zu lesen:

> […] Seit Jahresbeginn sind die Straftaten am Zürcher Hauptbahnhof markant gestiegen, der HB ist zu einem Brennpunkt geworden. Der zuständige Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) verortet «mehr Pöbeleien, mehr Delikte, mehr Konflikte». […]
>
> Auffallend ist, dass am Hauptbahnhof viel Alkohol konsumiert wird. Je reduzierter dieser aber vorhanden ist, desto weniger Probleme gebe es, fasste es die St. Galler Strafrechtlerin Nora Markwalder diese Woche gegenüber der NZZ zusammen. Gerade wenn Alkohol rund um die Uhr gekauft und konsumiert werden könne, sei das ein Risikofaktor. […]

Auch im Kanton X besteht das Problem, dass in städtischen Gebieten vermehrt Schlägereien und Pöbeleien auf öffentlichen Plätzen auszumachen sind. Besonders viele Schlägereien sind jeweils spätnachts, hauptsächlich an den Wochenenden, zu beobachten, wobei die beteiligten Personen in den allermeisten Fällen alkoholisiert sind.

Das Parlament des Kantons X hält die ständige Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken für einen erheblichen Risikofaktor und möchte deshalb hart durchgreifen. Es erlässt im kantonalen Gesetz über das Gastgewerbe (Gastgewerbegesetz) folgende neue Bestimmung:

> Art. 53*a* **Verbot des Verkaufs alkoholischer Getränke**
>
> Der Verkauf alkoholhaltiger Getränke zum Mitnehmen ist Gaststätten von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr verboten.

Die Schweizer Bürgerin Heidi, die in der Stadt Y im Kanton X eine Cocktailbar betreibt, ist verärgert über dieses Verbot. Ein Grossteil ihrer Kundschaft schätzt es nämlich sehr, dass Heidi ihre leckeren, wenn auch eher teuren Cocktails nicht nur zum Konsum vor Ort, sondern auch «über die Gasse» zum Mitnehmen anbietet. Heidi rechnet damit, dass ihr durch dieses Verbot eine erhebliche Umsatzeinbusse entstehen werde, was sie innerhalb weniger Monate in den finanziellen Ruin treiben würde. Am meisten ärgert sie jedoch, dass Peter, der gleich gegenüber der Bar einen Kiosk betreibt, der wie alle Verkaufsgeschäfte im Kanton X bis 22.00 Uhr geöffnet sein darf, nicht vom Verbot betroffen sein wird und weiterhin bis Ladenschluss seinen günstigen Alkohol (Bier und ungemischte Spirituosen) verkaufen darf. Dies deshalb, weil Kioske nicht als «Gast-stätten» im Sinn des Gastgewerbegesetzes gelten.

Entrüstet meldet sich Heidi bei Ihnen. Sie ist der Meinung, dass dieses zeitliche Verkaufsverbot ihre Wirtschaftsfreiheit verletze.

- Prüfen Sie anhand der Prüfkriterien, ob die **Wirtschaftsfreiheit** von Heidi eingeschränkt wird und ob die Einschränkung zulässig ist.
- **Prüfen Sie alle Kriterien, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.**
- Prozessuale Fragen können Sie weglassen.

Erster Teil der Prüfung: Wird die Wirtschaftsfreiheit eingeschränkt?

a) Rechtsgrundlage der Wirtschaftsfreiheit
Die Wirtschaftsfreiheit ist in Artikel 27 BV verankert.

b) Sachlicher Schutzbereich (Schutzobjekt)
Die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV):
Die Wirtschaftsfreiheit bedeutet das Recht der Einzelnen, uneingeschränkt von staatlichen Massnahmen jede privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit frei auszuüben und einen privatwirtschaftlichen Beruf frei zu wählen. Sie umfasst alle auf Erwerb gerichteten Tätigkeiten, also selbständige und unselbständige, haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten.

In casu: *Heidi betreibt eine Cocktailbar im Kanton X. Sie schenkt ihre Cocktails nicht nur zum Trinken vor Ort, sondern auch zum Mitnehmen aus, wobei Letzteres gemäss neuer gesetzlicher Regelung zu bestimmten Zeiten verboten werden sollte. Sie betreibt demnach eine privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit, die auf die Erzielung eines Gewinns ausgerichtet ist und durch das Verbot tangiert wird.*

Fazit: *Es wird somit in den geschützten Bereich der Wirtschaftsfreiheit eingegriffen.*

c) Persönlicher Schutzbereich (Grundrechtsträgerschaft)
Das Recht auf Wirtschaftsfreiheit steht Schweizerinnen und Schweizern sowie Ausländerinnen und Ausländern, die über eine Niederlassungsbewilligung verfügen oder einen gesetzlichen oder staatsvertraglichen Anspruch haben, zu. Weiter sind inländische juristische Personen des Privatrechts Träger der Wirtschaftsfreiheit (ausländische juristische Personen nur, wenn ein Anspruch auf wirtschaftliche Betätigung besteht).

In casu*: Bei Heidi handelt es sich um eine natürliche Person mit Schweizer Bürgerrecht.*

Fazit: *Heidi ist Trägerin der Wirtschaftsfreiheit.*

d) Adressat
Adressat der Wirtschaftsfreiheit ist der Staat bzw. sind alle Träger staatlicher Aufgaben, insbesondere sämtliche staatlichen Behörden auf allen Staatsebenen (Bund, Kantone, Gemeinden).

In casu: *Beim Parlament des Kantons X handelt es sich um eine staatliche Behörde auf Ebene Kanton, womit die Handlung von einem Grundrechtsverpflichteten ausgeht.*

Fazit: *Das Parlament des Kantons X ist Adressatin der Wirtschaftsfreiheit.*

e) Zwischenergebnis der Vorprüfung
Die Wirtschaftsfreiheit von Heidi wird eingeschränkt.

Zweiter Teil der Prüfung: Ist die Einschränkung zulässig (d.h. verfassungskonform: Art. 36 BV) oder wird die Wirtschaftsfreiheit verletzt?

Handelt es sich um eine grundsatzkonforme Massnahme (Art. 94 Abs. 1 BV)?
Zunächst ist zu beantworten, ob die zu beurteilende Massnahme grundsatzkonform ist, da sich Bund und Kantone grundsätzlich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit zu halten haben. Abweichungen von diesem Grundsatz, insbesondere Massnahmen, die sich gegen den Wettbewerb richten, bedürfen einer Grundlage in der Bundesverfassung (Art. 94 Abs. 4 BV).
Das Bundesgericht prüft die Frage der Grundsatzwidrigkeit traditionellerweise mit Blick auf das Regelungsmotiv der Behörden:
Als grundsatzkonforme Massnahmen gelten wirtschaftspolizeiliche Massnahmen, also diejenigen, welche der Gefahrenabwehr dienen und somit nicht wirtschaftspolitisch motiviert sind. Als grundsatzwidrige Massnahmen gelten wirtschaftspolitische Massnahmen, die den freien Wettbewerb behindern/verzerren, um gewisse Gewerbezweige oder Bewirtschaftungsformen zu sichern oder zu begünstigen.

In casu: *Es liegt eine grundsatzkonforme Massnahme vor, da die Massnahme wirtschaftspolizeilicher Natur ist. Es geht im vorliegenden Fall um die Eindämmung der Kriminalität auf den öffentlichen Plätzen des Kantons X, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.*

Fazit: *Es handelt sich um eine grundsatzkonforme Massnahme, weshalb sich die Frage der Zulässigkeit der Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit (ausschliesslich) nach Art. 36 BV richtet.*

a) Gesetzliche Grundlage
Art. 36 Abs. 1 BV
Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage. Eine Ausnahme bildet die polizeiliche Generalklausel (Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr).

Gemäss Art. 53a des Gastgewerbegesetzes des Kantons X ist den Gaststätten der Verkauf alkoholhaltiger Getränke zum Mitnehmen zwischen 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr untersagt.

Erfordernis des Rechtssatzes
- *Die Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich in einem Rechtssatz, d.h. in einer generell-abstrakten Norm, vorgesehen sein (Art. 22 Abs. 4 ParlG). Generell ist eine Norm, wenn sie sich an eine unbestimmte Zahl von Adressatinnen und Adressaten richtet, abstrakt ist eine Norm, wenn sie eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt.*
- *Der Rechtssatz muss überdies genügend bestimmt sein, d.h. er muss so präzise formuliert sein, dass die Einzelnen ihr Verhalten danach richten und die Folgen eines*

bestimmten Verhaltens mit einem entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können.

In casu: *Art. 53a des Gastgewerbegesetzes stellt eine generell-abstrakte Norm dar, da sie sich an eine unbestimmte Zahl von Adressatinnen und Adressaten richtet und eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt. Zudem ist Art. 53a des Gastgewerbegesetzes unter dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit genügend klar, so dass die Einzelnen ihr Verhalten entsprechend danach richten können.*

Zwischenfazit Erfordernis des Rechtssatzes*: Dieses Erfordernis ist erfüllt.*

Erfordernis der Gesetzesform
Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein, d.h. in einem Gesetz im formellen Sinn (Art. 36 Abs.1 Satz 2 BV). Nicht schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen können auch in Erlassen niedrigerer Stufe vorgesehen sein, insbesondere in einer Verordnung.

In casu: *Art. 53a des kantonalen Gastgewerbegesetzes wurde vom zuständigen Kantonsparlament erlassen. Beim Gastgewerbegesetz handelt es sich um ein Gesetz auf Stufe Kanton. Folglich stellt Art. 53 des Gastgewerbegesetzes eine formell-gesetzliche Grundlage dar, weshalb insoweit die Schwere des Grundrechtseingriffs unerheblich ist.*

Zwischenfazit Erfordernis der Gesetzesform*: Dieses Erfordernis ist erfüllt.*

Gesamtfazit gesetzliche Grundlage:
Das Erfordernis des bestimmten Rechtssatzes und das Erfordernis der Gesetzesform sind erfüllt. Art. 53a des Gastgewerbegesetzes stellt somit eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Einschränkung von Freiheitsrechten dar.

b) Rechtfertigendes Interesse
Art. 36 Abs. 2 BV
Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichendes öffentliches Interesse gilt etwa der Schutz der Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit, Treu und Glauben im Geschäftsverkehr). Weitere öffentliche Interessen ergeben sich aus der Bundesverfassung und der Gesetzgebung. Das Eingriffsinteresse des Schutzes von Grundrechten Dritter macht deutlich, dass die Grundrechtsansprüche verschiedener Grundrechtsträger miteinander kollidieren können.

In casu: *Das öffentliche Interesse besteht vor allem in der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung. Laut der im Zeitungsartikel wiedergegebenen Einschätzung der Strafrechtlerin Nora Markwalder besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Gewaltproblemen und der Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken. Die Regelung mit dem zeitlichen Verkaufsverbot soll deshalb dazu dienen, durch die Verminderung der Verfügbarkeit von Alkohol, insbesondere in der Nacht, Pöbeleien, Gewalttaten, Sachbeschädigungen sowie Lärmbelästigungen zu vermindern. Darüber hinaus trägt ein solches Verbot zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung (insbesondere auch der Jugendlichen) bei, indem der Zugang zu alkoholischen Getränken eingeschränkt wird. Es kann auch die Ansicht vertreten werden, dass mit dem Schutz der öffentlichen Sittlichkeit ein weiteres öffentliches Interesse eine Rolle spielen könnte, auch wenn der Begriff der öffentlichen Sittlichkeit höchst unbestimmt und in hohem Masse auslegungsbedürftig ist.*

Fazit: *Es liegen rechtfertigende Interessen vor.*

c) Verhältnismässigkeit
Art. 36 Abs. 3 BV
Eignung: *Die Massnahme muss geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen.*

In casu*: Grundsätzlich wäre ein Verkaufsverbot von Alkohol geeignet, den Konsum einzudämmen. Die Massnahme bietet allerdings ein gewisses Umgehungspotenzial: So könnten zwar alkoholische Getränke zum Mitnehmen nicht mehr in den Gaststätten (Bars usw.) gekauft werden, der Erwerb von (ungemischten) alkoholischen Getränken in Verkaufsgeschäften bis 22 Uhr ist aber weiterhin möglich, und dies erfahrungsgemäss zu einem viel tieferen Preis als in den Gaststätten. Ein Verbot, wie es Art. 53a des Gastgewerbegesetzes vorsieht, dürfte bis 22.00 Uhr praktisch wirkungslos sein. Nach 22.00 Uhr dürfte das Verbot jedoch eine gewisse Wirkung zeitigen, da ab dieser Uhrzeit Alkohol nur noch erworben werden kann, wenn er in der Gaststätte selbst konsumiert wird. Zwar könnte argumentiert werden, dass man Alkohol auch vorher kaufen oder von zu Hause mitnehmen könnte, allerdings dürfte das Verbot von Art. 53a des Gastgewerbegesetzes doch zu einer geringeren Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken und damit zu einem geringeren Alkoholkonsum führen.*

Fazit: *Die Eignung kann insgesamt wohl gerade noch bejaht werden.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Erforderlichkeit*: Die Massnahme muss den geringstmöglichen Eingriff darstellen; es darf keine gleichermassen geeignete, mildere Massnahme geben, die zum gleichen Ziel führen würde. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Beziehung nicht über das Notwendige hinausgehen.*

***In casu**: Die Tatsache, dass in Gaststätten weiterhin alkoholische Getränke ausgeschenkt werden dürfen, sofern sie vor Ort konsumiert werden, spricht dafür, dass das Verbot in sachlicher Hinsicht nicht über das Notwendige hinausgeht. Immerhin könnte man sich überlegen, ob man das Verbot nicht ausschliesslich auf hochprozentigen Alkohol hätte beschränken können bzw. müssen.*
In zeitlicher Hinsicht ist das Verbot allerdings zu weitgehend: Der Beginn des Verbots um 20.00 Uhr erscheint doch sehr früh angesetzt zu sein, da Schlägereien gemäss Sachverhalt vor allem spätnachts zu beobachten sind. Zudem beginnt das Alkoholverkaufsverbot für Gaststätten unverständlicherweise sogar zwei Stunden früher als für die Verkaufsgeschäfte (Kioske usw.), die bis Ladenschluss (gemäss Sachverhalt 22.00 Uhr) sehr günstigen Alkohol verkaufen dürfen. Da hauptsächlich die Wochenenden problematisch sind, könnte man sich überdies vorstellen, das Verkaufsverbot auf die Nächte von Freitag auf Samstag bzw. von Samstag auf Sonntag zu beschränken.
In räumlicher Hinsicht wäre eine Beschränkung des Verbots auf die unmittelbare Umgebung bestimmter neuralgischer Plätze weniger weitgehend und wohl dennoch wirksam. Ein kantonsweites Verbot erscheint als nicht notwendig.

***Fazit:** Die Erforderlichkeit ist nicht gegeben.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

***Zumutbarkeit:** Die Massnahme darf zu keinem Missverhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung führen (Zweck-Mittel-Verhältnis). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Grundrechts muss das private Interesse an dessen ungehinderter Ausübung überwiegen.*

***In casu (inkl. Abwägung):** Öffentliches Interesse an der Einschränkung: siehe oben.*
Privates Interesse: Interesse von Heidi, weiterhin Cocktails auch «über die Gasse» zum Mitnehmen zu verkaufen und damit eine erhebliche, u.U. existenzbedrohende Umsatzeinbusse zu verhindern.

Abwägung: Die öffentlichen Interessen umfassen die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, den Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und insbesondere von Jugendlichen.
Je reduzierter alkoholische Getränke vorhanden sind, desto weniger Schlägereien sind zu beobachten. Diese Ziele sind von erheblicher Bedeutung, da sie das Wohlbefinden und die Sicherheit einer grossen Zahl von Menschen betreffen, die sich spät nachts auf den Strassen aufhalten.
Allerdings kann die Eignung des Verkaufsverbots von 20.00 bis 22.00 Uhr insofern in Frage gestellt werden, als der billigere Alkohol leicht in den Verkaufsgeschäften gekauft werden kann. Während die Wirkung des Verbots auch nach 22.00 Uhr relativ gering sein dürfte, fällt die Einschränkung für Heidi doch sehr stark ins Gewicht, da ihre Kundschaft es sehr schätzt, die

Cocktails auch zum Mitnehmen zu kaufen. Gemäss Sachverhalt könnte das Verbot für Heidi gar existenzbedrohend sein. Die relativ bescheidene Wirkung des Verbots, die eher lange Dauer des Verkaufsverbots bereits ab 20.00 Uhr und die Tatsache, dass Heidi durch das Verbot in den finanziellen Ruin getrieben werden könnte, legt den Schluss nahe, dass die Einschränkung für Heidi nicht zumutbar ist.

Fazit: *Die Zumutbarkeit ist nicht gegeben.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Zwischenergebnis Verhältnismässigkeit*: Die Verhältnismässigkeit der Einschränkung ist zu verneinen.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

d) Kerngehaltswahrung

Art. 36 Abs. 4 BV

In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Grundrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.

Der Kerngehalt der Wirtschaftsfreiheit ergibt sich aus dem Gesichtspunkt der Entfaltung des Menschen in wirtschaftlichen Bereichen. Unzulässig wäre etwa der Zwang zum Erlernen oder Ausüben eines bestimmten Berufs oder überhaupt einer Erwerbstätigkeit. Der institutionelle Kerngehalt einer grundsätzlich wettbewerbsorientierten Wirtschaftsordnung wäre z.B. verletzt, wenn sich der Staat generell oder für ganze Lebensbereiche bei Marktentscheidungen ein Mitspracherecht ausbedingen würde. Unantastbarer Kern der Wirtschaftsfreiheit ist in diesem Sinne auch das Institut der Vertragsfreiheit. Umstritten ist, ob sich die Frage der Grundsatzwidrigkeit mit dem Kerngehalt des Grundrechts deckt. Dafür spricht, dass die Bundesverfassung grundsatzwidrige Massnahmen unter Verfassungsvorbehalt stellt (Art. 94 Abs. 4 BV). Andererseits ist fraglich, ob jede noch so geringe Beeinträchtigung des Grundsatzes der Wirtschaftsfreiheit wirklich den Kern des Grundrechts berührt. Der Kerngehalt dürfte in der Regel dort berührt sein, wo eine sehr schwere individuelle Beschränkung gleichzeitig dem Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit widerspricht.

In casu: *Heidi wird weder ein Zwang zum Erlernen noch zum Ausüben eines bestimmten Berufs/einer bestimmten Tätigkeit auferlegt.*

Fazit: *Der Kerngehalt der Wirtschaftsfreiheit wird gewahrt.*

e) Gleichbehandlung der direkten Konkurrentinnen und Konkurrenten?

Aus der Wirtschaftsfreiheit wird ein Anspruch der direkten Konkurrenten auf Gleichbehandlung abgeleitet. Nach diesem Grundsatz sind Massnahmen verboten, die den Wettbewerb unter direkten Konkurrenten verzerren bzw. nicht wettbewerbsneutral sind. Als direkte Konkurrenten gelten Angehörige der gleichen Branche, die sich mit gleichem Angebot an dasselbe Publikum richten, um dasselbe Bedürfnis zu befriedigen.
Die Gleichbehandlung der direkten Konkurrenten hat überdies keine absolute Geltung: Ungleichbehandlungen erweisen sich als zulässig, wenn sie sich auf ernsthafte sachliche Gründe stützen können. So hat das Bundesgericht die Privilegierung gewisser Verfahren, Produkte oder Anbieterinnen und Anbieter etwa aus Gründen des Umweltschutzes oder zwecks Kosteneindämmung im Gesundheitswesen als gerechtfertigt angesehen, auch wenn sich dadurch gewisse Auswirkungen auf das Verhältnis Konkurrenten ergeben.

***In casu**: Es stellt sich hier die Frage, ob Heidi mit ihrem Verkauf der (eher teuren) Cocktails «über die Gasse» zum Mitnehmen in direkter Konkurrenz zu Peter steht, der in seinem Kiosk günstigen Alkohol (Bier und ungemischte Spirituosen) verkauft.*

Heidi und Peter gehören nicht der gleichen Branche an, da es sich bei Heidis teuren Cocktails und Peters billigem Alkohol um unterschiedliche Angebote handelt, die der Erfüllung unterschiedlicher Bedürfnisse dienen und die beiden somit eine unterschiedliche Zielgruppe ansprechen dürften. Heidis Angebot richtet sich eher an ein gehobenes, zahlungskräftiges Publikum, Peters Angebot vor allem an jüngere Personen bzw. einkommensschwächere Personen. Heidi und Peter sind somit keine direkten Konkurrenten, weshalb keine Ungleichbehandlung direkter Konkurrenten vorliegt.

***Fazit:** Die Gleichbehandlung der direkten Konkurrenten ist gewahrt.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

f) Gesamtergebnis
Die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit ist unzulässig.

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Vgl. zum Ganzen BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, §§ 30, 31, 32, 34 und 37
Vorlesung 2. Teil (III) Folien 14 ff.